


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

TERMO AUDIÊNCIA

Processo nº **0000791-23.2017.8.26.0050**
 Réu **EDIO BARBOSA PEREIRA**
 Artigo da Denúncia: 157, §2º, I do CP e art. 33, caput da Lei 11.343/06

Aos 01/06/2017, às 14:30h, na sala de audiências da 15ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Marcos Alexandre Coelho Zilli, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, PRESENTES o réu EDIO BARBOSA, bem como as testemunhas WILLIAM SILVA e MARCOS ANTONIO. AUSENTE a vítima DANIEL ARAUJO, que encontra-se em lugar incerto e não sabido.

Presente o Promotor de Justiça, Dr. **Celso Élio Vannuzini** e a Defensora Pública em exercício nesta vara, **Dra. Mônica de Melo**.

O réu foi mantido algemado durante a audiência diante da ausência de escolta suficiente que pudesse resguardar a segurança, havendo experiências anteriores nas dependências deste Fórum de tentativas de fugas de réus algemados.

Dada a palavra ao Promotor de Justiça, pelo mesmo, foi dito: “MM Juiz, DESISTO da oitiva da testemunha DANIEL.” O que foi homologado pelo MM Juiz.

A seguir, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa: WILLIAM SILVA e MARCOS ANTONIO FREITAS.

Assim sendo, após ser entrevistado por sua defensora, deu-se o interrogatório do réu.

Encerrada a instrução foi dada a palavra às partes, para pedidos de diligências, por estas foi dito que nada havia para ser requerido.

Na sequência, foi dado início aos debates, dada a palavra ao Promotor de Justiça, pelo mesmo foi dito: “MM Juiz, EDIO BARBOSA PEREIRA foi denunciado como incurso nos artigos 157, § 2º, I, do Código Penal e 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 69 do Código Penal. Narra a denúncia que no dia 10 de janeiro de 2017, por volta das 17 horas, na Rua Aracati, na altura do nº 275, Penha, nesta Capital, o acusado subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, um aparelho celular, marca LG, pertencente a Daniel Araújo de Souza. Narra, ainda, que no mesmo dia, por volta das 20 horas, nesta Capital, o acusado trazia consigo, para fim de tráfico, 04 pinos de cocaína, 47 porções de maconha e 37 pedras de “crack”, com pesos de 3,9 gramas; 72 gramas e 6,3 gramas, respectivamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A ação proposta merece procedência. O acusado foi preso em flagrante. A flagrância, tanto para a doutrina como para a jurisprudência, é a mais eloquente prova de autoria e materialidade de uma infração penal. A materialidade do tráfico também restou comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 143/145. Quanto ao roubo, restou comprovada pela apreensão, em poder do acusado, do celular subtraído (auto de exibição e apreensão de fl. 18/19). Como é cediço, nos crimes patrimoniais, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca; assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

presunção em certeza, autorizando a condenação. Em poder do acusado, os policiais também apreenderam a faca utilizada na prática do roubo (fl. 18/19). A vítima, na fase extrajudicial, reconheceu o acusado como o autor do delito. Os policiais militares Daniel Aparecido de Jesus e Diego Ferreira de Moura, nos depoimentos de fls. 166/167 (mídias anexas), esclareceram que realizavam patrulhamento de rotina, ocasião em que foram acionados pela vítima, que noticiava a prática do roubo sofrido; passou as características do roubador e de seus trajes (bermuda amarela e camiseta branca e azul, de time de futebol); ingressaram numa comunidade, ocasião em que avistaram o acusado, cujas características coincidiam; realizaram sua abordagem e apreenderam o celular subtraído, uma faca, aproximadamente cento e cinquenta reais e as drogas citadas na denúncia; o acusado afirmou que o celular era de um primo; a vítima reconheceu o acusado e o celular apreendido; no celular, inclusive, havia fotos da vítima e da esposa; não conheciam o acusado de outras abordagens. As versões apresentadas pelos policiais merecem credibilidade, pois sequer conheciam o acusado, inexistindo razões para que o incriminassem falsamente. Conforme entendimento jurisprudencial, *“a simples condição de policial não torna a testemunha impedida”* (RTJ 68/54), *“mostrando-se inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado.”* RENATO MARCÃO destaca que *“o testemunho policial goza de presunção de credibilidade. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções – TJSP, Ap. Crim. 160.291-3, 2ª Câ. Crim., rel. Des. Devienne Ferraz, j. 30-05-1994, JTJ 159/310”* - (TÓXICOS, Saraiva, São Paulo, 8ª edição, 2011, página 199). O eminente Desembargador RENÊ RICUPERO, em caso semelhante (Apelação Criminal nº 990.10.157710-0, da comarca de São Paulo), discorrendo sobre o tema, com muita propriedade, assim decidiu: *“Em crime de entorpecente, a palavra do policial, investido regularmente no desempenho de função pública, ao dar conta de sua atividade oficial, goza de presunção de veracidade até prova em contrário, que não pode ser a impugnação genérica, sem nenhuma ligação específica com o fato apurado e as pessoas nele envolvidas. A suspeição do policial não pode decorrer unicamente de sua condição profissional, uma vez que a lei processual não faz qualquer distinção, prescrevendo que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202 do CPP). Se o policial pode ser testemunha, a sua palavra serve para formar o convencimento judicial e alicerçar a condenação do acusado, desde que se encontre afinada com outros elementos probatórios, ainda que indiciários.”* A testemunha arrolada pela defesa, William Silva, prestou depoimento falso, totalmente divergente gravidade do crime perpetrado (roubo qualificado com emprego de arma de fogo) constitui circunstância concreta que recomenda o estabelecimento do regime fechado como o inicial de cumprimento da pena, de modo a impedir a constante repetição de atos nocivos que trazem intranquilidade e desassossego à população. Conforme consta do julgado inserto “in” RJTACRIM 37/314, *“Em se tratando de roubo, crime cuja execução revela personalidade marcadamente perigosa, fechado é o único regime ajustável ao princípio da necessidade e suficiência.”* A 6ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, apreciando a Apelação nº 0081644-63.2010.8.26.0050, da comarca de São Paulo, relativa a crime de roubo praticado em concurso de agentes, sendo relator o eminente Desembargador SILMAR FERNANDES, assim decidiu: *“... o regime fechado para o desconto inicial da pena da pena foi bem eleito, pois se mostra o mais adequado para atender às finalidades preventiva, retributiva e educativa da sanção penal. São crimes como o tratado nos autos que mantém a sociedade em constante estado de temor*


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

e intranquilidade, pela audácia e sangue frio com que agem pessoas como os réus, cabendo ao Poder Judiciário, nas circunstâncias atuais, combater esse trauma coletivo de medo, reeducando essas pessoas e estabelecendo a calma aos cidadãos que cumprem as normas para o convívio em sociedade. Sobre o tema: 'o regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda que se trata de réu primário' (HC nº 74.301-3, origem São Paulo, DJU 6.12.96, pág. 48.711.)” No mesmo sentido, o julgado que segue: “STJ. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. DESFAVORABILIDADE. ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA DELITUOSA PRATICADA. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS. ILEGALIDADE AUSENTE. 1. (...) REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MANUTENÇÃO JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. Inviável a imposição do modo intermediário de cumprimento de pena, pois, não obstante a reprimenda do paciente tenha sido definitivamente estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o modus operandi empregado no cometimento dos delitos revela a gravidade concreta dos ilícitos perpetrados e a periculosidade do acusado. 2. (...) (HC 163.591/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, 5ª Turma, julgado em 24/05/2011, DJE 02/06/2011).” A 6ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, apreciando a apelação nº 0004034.2007.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, sendo relatora a eminente Desembargadora ROSSANA TERESA CURIONI MERGULHÃO, assim decidiu: “O artigo 33 e seus parágrafos, do Código Penal, estabelecem os critérios para a fixação do regime inicial da pena. Entretanto, a fixação do regime inicial não se baseia apenas no critério da quantidade da pena, mas também nas circunstâncias e outros requisitos que devem ser plenamente favoráveis para aplicação de regime mais brando. Nesse sentido: No crime de roubo, o regime inicial fixado para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza vêm aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são praticados, o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo pela integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza da infração, tais circunstâncias – previstas no art. 59 do CP – devem ser sopesadas na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do § 3º do art. 33 do referido Diploma Legal.” A gravidade do crime perpetrado (roubo qualificado com emprego de arma) constitui circunstância concreta que recomenda o estabelecimento do regime fechado como o inicial de cumprimento da pena, de modo a impedir a constante repetição de atos nocivos que trazem intranquilidade e desassossego à população. Conforme consta do julgado inserto “in” RJTACRIM 37/314, “Em se tratando de roubo, crime cuja execução revela personalidade marcadamente perigosa, fechado é o único regime ajustável ao princípio da necessidade e suficiência.” A 6ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, apreciando a Apelação nº 0081644-63.2010.8.26.0050, da comarca de São Paulo, relativa a crime de roubo praticado em concurso de agentes, sendo relator o eminente Desembargador SILMAR FERNANDES, assim decidiu: “... o regime fechado para o desconto inicial da pena da pena foi bem eleito, pois se mostra o mais adequado para atender às finalidades preventiva, retributiva e educativa da sanção penal. São crimes como o tratado nos autos que mantém a sociedade em constante estado de temor e intranquilidade, pela audácia e sangue frio com que agem pessoas como os réus, cabendo ao Poder Judiciário, nas circunstâncias


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

atuais, combater esse trauma coletivo de medo, reeducando essas pessoas e estabelecendo a calma aos cidadãos que cumprem as normas para o convívio em sociedade. Sobre o tema: 'o regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda que se trata de réu primário' (HC nº 74.301-3, origem São Paulo, DJU 6.12.96, pág. 48.711.)” No mesmo sentido, o julgado que segue: “STJ. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. DESFAVORABILIDADE. ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA DELITUOSA PRATICADA. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS. ILEGALIDADE AUSENTE. 1. (...) REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MANUTENÇÃO JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. Inviável a imposição do modo intermediário de cumprimento de pena, pois, não obstante a reprimenda do paciente tenha sido definitivamente estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o modus operandi empregado no cometimento dos delitos revela a gravidade concreta dos ilícitos perpetrados e a periculosidade do acusado. 2. (...) (HC 163.591/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, 5ª Turma, julgado em 24/05/2011, DJE 02/06/2011).” A testemunha arrolada pela defesa, William Silva, prestou depoimento falso, conflitante com os prestados pelos policiais, que se revelaram harmônicos e seguros. O acusado, em seu interrogatório, negou a prática dos delitos. Destarte, o conjunto probatório, de forma harmônica e segura, permite a prolação de uma sentença condenatória. Como é cediço, “para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga a terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado” (TJSP, Ap. 187.915-3/2, 5ª Câmara, j. 30-11-1995, rel. Des. CHRISTIANO KUNTZ, RT 737/478). Foi apreendida expressiva quantidade de drogas: 04 pinos de cocaína, 47 porções de maconha e 37 pedras de “crack”, com pesos de 3,9 gramas; 72 gramas e 6,3 gramas, respectivamente. Convém destacar, a título de comparação, que um “fininho” de maconha equivale a 0,33 grama (“Tudo sobre Drogas”, Maconha, Chris - Ellyn Johanson, Nova Cultural). Conforme consta do julgado inserto “in” RT 543/382, “a quantia de 14 gramas de maconha é razoável e suficiente para exteriorizar ato de tráfico, notadamente se repartida em pacotinhos, denotando o intuito de venda.” Por outro lado, os usuários de cocaína tidos como mais experientes ou de maior frequência administram a droga por via intravenosa. A dose normal costuma ser de 10 mg. (“Tudo sobre Drogas”, Cocaína, Chris - Ellyn Johanson, Nova Cultural). Destarte, o conjunto probatório, de forma harmônica e segura, permite a prolação de uma sentença condenatória. O acusado é primário, circunstância que deve ser considerada na aplicação da pena-base, ao lado das demais previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como às previstas no artigo 42 da Lei de Drogas, notadamente a quantidade de drogas. Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstância atenuantes ou agravantes. Na terceira fase da dosimetria, mostra-se cabível o reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Configurada, ainda, a causa de aumento do emprego de arma (faca). A hipótese dos autos revela a configuração do concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal). O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, considerando as circunstâncias do caso concreto e a gravidade diferenciada dos crimes praticados. A gravidade do crime patrimonial perpetrado (roubo qualificado com emprego de arma) constitui circunstância concreta que recomenda o estabelecimento do regime fechado como o inicial de cumprimento da pena, de modo a impedir a constante repetição de atos nocivos


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

que trazem intranquilidade e desassossego à população. Conforme consta do julgado inserto “in” RJTACRIM 37/314, “*Em se tratando de roubo, crime cuja execução revela personalidade marcadamente perigosa, fechado é o único regime ajustável ao princípio da necessidade e suficiência.*” A 6ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, apreciando a Apelação nº 0081644-63.2010.8.26.0050, da comarca de São Paulo, relativa a crime de roubo praticado em concurso de agentes, sendo relator o eminente Desembargador SILMAR FERNANDES, assim decidiu: “... o regime fechado para o desconto inicial da pena da pena foi bem eleito, pois se mostra o mais adequado para atender às finalidades preventiva, retributiva e educativa da sanção penal. São crimes como o tratado nos autos que mantém a sociedade em constante estado de temor e intranquilidade, pela audácia e sangue frio com que agem pessoas como os réus, cabendo ao Poder Judiciário, nas circunstâncias atuais, combater esse trauma coletivo de medo, reeducando essas pessoas e estabelecendo a calma aos cidadãos que cumprem as normas para o convívio em sociedade. Sobre o tema: ‘o regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda que se trata de réu primário’ (HC nº 74.301-3, origem São Paulo, DJU 6.12.96, pág. 48.711.)” No mesmo sentido, o julgado que segue: “STJ. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. DESFAVORABILIDADE. ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA DELITUOSA PRATICADA. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS. ILEGALIDADE AUSENTE. 1. (...) REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MANUTENÇÃO JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. Inviável a imposição do modo intermediário de cumprimento de pena, pois, não obstante a reprimenda do paciente tenha sido definitivamente estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o modus operandi empregado no cometimento dos delitos revela a gravidade concreta dos ilícitos perpetrados e a periculosidade do acusado. 2. (...) (HC 163.591/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, 5ª Turma, julgado em 24/05/2011, DJE 02/06/2011).” A 6ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, apreciando a apelação nº 0004034.2007.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, sendo relatora a eminente Desembargadora ROSSANA TERESA CURIONI MERGULHÃO, assim decidiu: “O artigo 33 e seus parágrafos, do Código Penal, estabelecem os critérios para a fixação do regime inicial da pena. Entretanto, a fixação do regime inicial não se baseia apenas no critério da quantidade da pena, mas também nas circunstâncias e outros requisitos que devem ser plenamente favoráveis para aplicação de regime mais brando. Nesse sentido: No crime de roubo, o regime inicial fixado para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza vêm aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são praticados, o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo pela integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza da infração, tais circunstâncias – previstas no art. 59 do CP – devem ser sopesadas na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do § 3º do art. 33 do referido Diploma Legal.” Cumpre destacar que a Resolução nº 05/12, do Senado Federal, decorrente da decisão do STF, que suspendeu a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” (artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas), diz respeito à impossibilidade de vedação absoluta da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Todavia, não se reconheceu



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

a obrigatoriedade da substituição, que depende do preenchimento de diversos requisitos de caráter subjetivo. O crime de tráfico de drogas provoca grave risco à saúde pública de um número indeterminado de pessoas, revelando-se insuficiente a sanção restritiva para a prevenção do fato criminoso. Ademais, mostra-se paradoxal que se permita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em caso tão grave, em que o regime inicial fechado é o mais adequado considerando as circunstâncias do caso concreto e a gravidade diferenciada do crime praticado. O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em data recente, mesmo depois da edição da referida resolução, afastou a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Conforme voto do eminente Desembargador CAMILO LÉLLIS, “*os fatos concretamente analisados são graves. Cuida-se de crime que impulsiona a prática de uma verdadeira cadeia delitiva, assolando a sociedade como um câncer, de maneira que a substituição das penas não se mostra socialmente recomendável e suficiente para a prevenção e repressão do delito*” (Apelação nº 0041976-38.2009.8.26.0562, comarca de Santos, 8ª Câmara Criminal, j. 23.08.2012). Diante do exposto, requeiro: a) a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia; b) o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União; c) a extração de cópias das principais peças dos autos, inclusive mídias, e sua remessa ao Ministério Público, visando à instauração de inquérito policial pelo crime de falso testemunho.”

Dada a palavra à defensora do réu, pela mesma foi dito: “MM Juiz, a vítima do roubo não foi localizada e não foi ouvida. A testemunha PM Daniel em seu depoimento relatou que estava em patrulhamento na via pública e foram solicitados por um rapaz que tinha sido vítima de roubo. Disse que era usuário de drogas e adquiriu crack e que a pessoa que vendeu com o uso de uma faca pegou seu celular e o mandou ir embora. Passou as características dessa pessoa e foram até o local e a vítima ficou na segurança de outro policial na viatura. Viram o réu conversando com outra pessoa e estaria com uma sacola na mão. Fizeram a revista e localizaram na sacola drogas, maconha, cocaína e crack. No DP a vítima reconheceu o acusado e o aparelho celular. A pessoa que estava conversando com o réu foi levada para averiguação. A sacola estava nas mãos do réu. Ele disse que o celular seria de um primo, mas no celular tinha foto da vítima. A testemunha PM Diego em seu depoimento relatou que estava em patrulhamento quando foram acionados pela vítima e falou que era usuário de drogas e que tinha sido roubado. Pediram para passar o local e as características. A vítima foi convidada a entrar na viatura e foi com eles até lá. Pelas roupas localizaram o réu que teria com uma faca pegado o celular da vítima. Avistaram o réu e outra pessoa ao lado dele. Na vistoria tinha uma pequena sacola com as drogas e no bolso o celular. Tinha dinheiro e na cintura uma faca pequena. Encaminharam os dois ao DP. A vítima reconheceu o celular com foto dela e o réu no DP. A faca foi apreendida. Tinha cocaína. Maconha, crack. Não haviam mais pessoas além dos dois que foram abordados. Tinha cerca de 150 reais no bolso dele. Ele não deu nenhuma explicação para as drogas mas teria dito que o celular era de um primo dele. Porém no DP se constatou que o celular seria da vítima, pois tinha fotos dela. A testemunha de defesa William Silva em seu depoimento relatou que estava junto com o acusado quando ele foi detido. Estava na porta da casa da avó dele quando chegou o réu com saco de lixo e entregou para a avó dele. Falou para fumarem um baseado e ele tinha. Foram até um bar e pegaram uma cerveja. Uma pessoa apareceu e pediu para vender o celular. O réu deu 70 reais e comprou o celular. Conhecia a pessoa que vendeu o celular de vista pois ele era cobrador de um ônibus na comunidade. Ele chegou ofereceu um celular e o vendeu por 70 reais. Depois voltou e disse que queria o celular de volta, mas o réu pediu então que devolvesse o dinheiro dele. Como ele não


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

devolveu ele também não devolveu e foi embora. Estavam com um baseado. Pegou o baseado no centro. Fizeram uso da maconha. Os policiais não mostraram as drogas. Não conhecia os policiais antes dos fatos. A testemunha de defesa Marcos em seu depoimento relatou que o réu tinha trabalhado para ela no dia em que foi preso. Trabalhava como extrusor em empresa que recicla plásticos há 9 meses. Saiu com sacos de lixo para entregar para a avó de William. Conhece ele há 5 anos. Ele ganhava 1.200 reais por mês. Nesse dia ele teria pedido um adiantamento de 200 reais. Depois soube que ele foi preso neste dia. O réu em seu interrogatório disse que nunca foi processado. Trabalhava de extrusor numa fábrica de fazer sacos de lixo. O patrão pediu para entregar saco de lixo para a avó de William e “trombou” com William e foram fumar um baseado. Apareceu a vítima e ofereceu um celular primeiro para William que não se interessou. Depois ofereceu para ele e ele pagou 70 reais. Depois a vítima voltou e se arrependeu e queria o celular de volta. Só tinha um baseado que estavam fumando. Não tinha sacola plástica e nem faca. Estava trabalhando. Não tinham nada. Só foi saber dessa sacola e faca na custódia. Na delegacia só tinha o dinheiro e o celular. Sempre trabalhou e não mexe com essas coisas. Ficou com William por mais de uma hora porque estava tomando uma cerveja. Os policiais disseram que ia leva-lo para averiguação. Não conhecia os policiais anteriormente. A droga que estava consumindo era de William, pois a avó dele mora na rua em que ele trabalha. **I - DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS** O conjunto de depoimentos não autorizariam uma condenação por tráfico e tampouco por roubo. A vítima não compareceu em juízo para prestar depoimento, realizar o necessário reconhecimento judicial sob o crivo do contraditório e ampla defesa, restando apenas indiretamente a fala da vítima através do depoimento dos policiais. O réu em seu interrogatório não nega que estivesse de posse do celular da vítima, mas apresentou versão de que a mesma teria vendido o aparelho para ele por 70 reais, o que foi confirmado pela testemunha de defesa William que estava junto com o réu quando este foi preso e acompanhou toda a abordagem dos policiais, sendo que também foi detida neste dia para averiguação. A testemunha William disse que estavam fumando um baseado e tomando cerveja quando foram procuradas pela vítima que ofereceu um celular para William, que não se interessou, sendo o aparelho vendido para o acusado. Depois a vítima se arrependeu e voltou querendo o celular de volta, mas não tinha mais o dinheiro. Não havia nenhuma droga com eles. Tampouco William teria visto uma faca em poder do acusado. A testemunha de defesa Marcos Antônio confirmou que conhecia o acusado há 5 anos e que ele trabalhava para ele há 9 meses com reciclagem para produção de sacos de lixo e que, inclusive, tinha trabalhado neste dia. Dessa forma, não há prova suficiente para uma condenação por tráfico, nem por roubo. As afirmações dos policiais militares em cotejo com a ausência da vítima e o testemunho de William e Marcos não permitem extrair elementos suficientes para uma condenação. Em razão da insegurança jurídica deixada pela situação narrada, defende-se aqui a ideia de que, quando absolutamente isolado e contraditório os depoimentos das agentes responsáveis pela ocorrência não podem suportar uma decisão condenatória. Do contrário, a exceção acaba por transforma-se em regra, permitindo que o aparelho repressor do Estado praticamente decida quem será processado e quem ao final será condenado. Com efeito, não se nega a nobreza da função ou a honestidade da instituição. Pelo contrário, sabe-se que são os grandes responsáveis pela segurança pública de um Estado. Contudo, o processo penal é regido por princípios constitucionais que protegem a liberdade humana e limitam o jus puniendi do Estado Democrático de Direito, o qual tem por fundamento a dignidade da pessoa humana. Sendo assim, qualquer ingerência na esfera pessoal deve estar amparada pela Constituição Federal. Pretende-se argumentar que, um sistema


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

processual penal não pode conter falhas, obscuridades e/ou incertezas. O suporte condenatório deve ser CERTO. A atual sistemática de investigação, que despreza toda prova que não emane dos próprios agentes do estado, sob o pretexto de que ninguém se presta a colaborar com a polícia ou com a justiça (verdadeiro sofisma, pois esta não é uma faculdade e sim um dever do cidadão - o que garante ao policial o direito de exercer a autoridade que se fizer necessária para a colheita da prova) acaba por transferir aos policiais que efetuam a prisão poder imensurável na persecução penal. Se aceito como verdade absoluta o depoimento daqueles, qual a possibilidade de defesa do acusado? O processo penal, sob a ótica constitucional, não pode admitir que a verdade seja posta por uma das partes. In casu, a verdade é posta por aqueles que efetuam a prisão. Ora, por que não acolher a versão do réu em detrimento da versão dos policiais? Por mais honesto que seja, será que um policial iria desdizer o seu parceiro? Se o fizesse, em tese, alguém incorreria em falso testemunho e/ou, eventualmente, em crime de abuso de autoridade. Constata-se, assim, que a condenação baseada exclusivamente em tais depoimentos, fere frontalmente o princípio do contraditório em seu aspecto substantivo, também denominado na doutrina alemã de “PODER DE INFLUÊNCIA”.

Diante das circunstâncias colocadas, qual o poder de influência do réu? Nenhum! Destarte, a interpretação atual de autorizar tais testemunhos, isoladamente, revela-se inconstitucional por afronta patente ao contraditório substancial. O professor Fredie Didier Jr., aborda com maestria a temática dos princípios processuais constitucionais, aplicados, com maior razão, ao processo penal: *“O processo é um instrumento de composição de conflito – pacificação social – que se realiza sob o manto do contraditório. O contraditório é inerente ao processo. Trata-se de princípio que pode ser decomposto em duas garantias: participação (audiência; comunicação; ciência) e possibilidade de influência na decisão. Aplica-se o princípio do contraditório, derivado que é do devido processo legal, nos âmbitos jurisdicional, administrativo e negocial. Democracia no processo recebe o nome de contraditório. Democracia é participação; e a participação no processo se opera pela efetivação da garantia do contraditório. O princípio do contraditório deve ser visto como manifestação do exercício democrático de um poder. Quais são os elementos que compõe a garantia do contraditório? Esta garantia desdobra-se em duas facetas. A faceta básica, que eu reputo a formal, é a da participação; a garantia de ser ouvido, de participar do processo, de ser comunicado, poder falar no processo. Isso é o mínimo e é o que todo mundo entende como princípio do contraditório. De acordo com o pensamento clássico, o magistrado efetiva, plenamente, a garantia do contraditório simplesmente ao dar ensejo à ouvida da parte, ao deixar a parte falar. Mas não é só isso. Há o elemento substancial dessa garantia, há um aspecto, que eu reputo essencial, denominado, de acordo com a doutrina alemã, de 'poder de influência'. Não adianta permitir que a parte, simplesmente, participe do processo; que ela seja ouvida. Apenas isso não é o suficiente para que se efetive o princípio do contraditório. É necessário que se permita que ela seja ouvida, é claro, mas em condições de poder influenciar a decisão do magistrado. Se não for conferida a possibilidade de a parte influenciar a decisão do Magistrado – e isso é poder de influência, poder de interferir na decisão do Magistrado, interferir com argumentos, interferir com idéias, com fatos novos, com argumentos jurídicos novos; se ela não puder fazer isso, a garantia do contraditório estará ferida. É fundamental perceber isso: o contraditório não se implementa, pura e simplesmente, com a ouvida, com a participação; exige-se a participação com a possibilidade, conferida à parte, de influenciar no conteúdo da decisão. Como poderia o magistrado punir alguém, sem que lhe tenha dado a chance de manifestar-se sobre os fundamentos da punição, por exemplo,*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

demonstrando que os fatos em que se baseia o magistrado ou não ocorreram ou não permitem a aplicação da sanção? Seria punir sem ouvir; seria condenar sem dar a chance de defesa. Não é possível a aplicação de qualquer punição processual, sem que se dê oportunidade ao 'possível punido' manifestar-se previamente, de modo a que possa, de alguma forma, influenciar no resultado da decisão". (Curso de Direito Processual Civil, Edições Podivm, Páginas 42/43) De se destacar que o sistemático desprezo da palavra do réu em favor do depoimento do agente isolado viola ainda o princípio in dubio pro reo, já que a contrariedade existente entre estas provas se resolve em condenação e não absolvição. Em sentido oposto, quando a prova da acusação se resume exclusivamente a palavra dos agentes, não havendo razões para reputar como incrível ou inverossímil a defesa apresentada pelos réus e por suas testemunhas é o caso de absolvê-los por insuficiência probatória, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. Em recente decisão assim manifestou-se o Tribunal de Justiça de São Paulo, (Apelação nº 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Des. SYDNEI DE OLIVEIRA JR., 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgado aos 03 de março de 2011), em caso também envolvendo suposta traficância, e tendo como únicas provas os depoimentos policiais, o qual pela importância se transcreve: "(...) Afinal de contas, as versões apresentadas se chocam e entrechocam, sendo salutar socorrer-se do vetusto in dubio pro reo. Uma vez presente à dúvida, presume-se, sem pestanejar, a inocência do acusado. Afinal de contas, in dubio pro libertate ou libertas omnibus rebus favorabilior est - na dúvida, pela liberdade; ou, em todas as coisas, a liberdade é mais favorecida, já diziam os romanos (CAIO. De regulis iuris. Digesto, Livro 50, Título 17), cujas locuções latinas são precursoras do conhecido e atual in dubio pro reo (...)"'. "(...) não se está sustentado a completa inaptidão do testemunho de policial, em sede de processo criminal. O que se defende é coisa bem outra. Os policiais militares investigadores do fato, como verdadeiros assistentes da parte autora, não têm, sozinhos, em face da própria condição de servirem como longa manus do Ministério Público, enquanto ditam as provas, a isenção suficiente para demarcarem, através de seus exclusivos depoimentos, um justo e razoável juízo de reprovação penal. Admitir-se entendimento outro é o mesmo que fazer ouvidos moucos ao som do retumbante princípio da proporcionalidade, desequilibrando, a não mais bastar, as atuações dos atores processuais, em manifesto e desmesurado prejuízo à ampla defesa do acusado, tornando-o sempre a parte vulnerável da ação penal, com mínimas chances, para não se dizer nenhuma, de se ver livre da imputação (...)"'. (Grifo nosso) "(...) É certo que os policiais não estão impedidos de depor - e isso nem se discute -, mas, porque prenderam certo acusado, seus exclusivos depoimentos não se apresentam idôneos para um definitivo esclarecimento da verdade processual, ou para embasar, com a segurança desejada, um justo édito condenatório do preso. Não são, certamente, imparciais, ainda mais quando, como no caso, suas falas são desmentidas pelo incriminado (...)"'. (Grifo nosso) Conforme se observa, o acórdão supra aplica-se como uma luva ao caso em testilha. As versões dos milicianos não foram confrontadas com nenhuma outra prova trazida aos autos. Assim, imperiosa a absolvição do réu, acompanhando-se consolidado entendimento dos Tribunais: "Uma sentença condenatória somente pode ser proferida diante da mais completa certeza. Havendo dúvida, chegando as provas somente ao crível, a justa solução é a absolvição" (RT 453/414). "Para um decreto condenatório, é indispensável a existência de provas seguras, precisas, não bastando suspeitas ou indícios, mesmo que sejam veementes" (JUTACRIM 62/206). "Sendo conflitante a prova e não podendo dar prevalência a esta ou àquela versão, é prudente a decisão que absolver o réu"


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

(TACRIM-SP – AP- Rel. Cunha Camargo – JUTACRIM – 20/370). “Sendo impossível optar com segurança entre as versões da vítima e dos acusados, quando nenhuma delas vem alicerçada em alguns outros adminículos objetivo fornecido pelos autos, é impositivo que se decrete a absolvição dos réus” (TACRIM-SP- AP- Rel. Érix Ferreira – RJD 24/37). Face ao exposto requer seja julgado improcedente a ação penal a fim de absolver o réu com fulcro no art.386, VII do CPP, devendo-se aplicar o princípio do in dubio pro reo. Na hipótese de outro ser o entendimento de V. Exa. vem deduzir os seguintes pedidos subsidiários. **II - DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE USO DE ARMA** A causa de aumento de pena prevista no § 2º, I do art. 157 não pode ser aplicada porque o objeto usado não foi uma arma. O objeto apreendido segundo o laudo pericial seria uma “faca de cozinha” em péssimo estado de conservação. Portanto, não enseja a aplicação da causa de aumento de pena prevista no §2º do art. 157 do C.P., pois o império do princípio da legalidade impõe considerar como armas apenas aquelas classificadas pela doutrina como próprias, ou seja, os instrumentos concebidos e utilizados primordialmente para defesa ou ataque, pois como ressalta a doutrina: “O tipo penal não iria valer-se da acepção ampla do termo, ou seja, não se refere às armas impróprias, mas unicamente às próprias, que apresentam maior perigo à incolumidade física da vítima” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, RT, 2000, p. 445). De forma idêntica manifestam-se nossos tribunais: “Instrumento metálico inoxidado, no formato de um arame pouco maleável - A utilização de arma imprópria não enseja a aplicação da qualificadora prevista no art. 157, §2º, n. I do CP, sendo imprescindível para tanto que o instrumento utilizado tipifique a arma em face da Lei de Contravenções Penais” (TAMG - AC - Rel. Carlos Biasutti - RTJE 110/273). “Agente que usa objeto em forma de garfo, próprio para esticar cabelo, para ameaça a vítima - A configuração da agravante do roubo exige o emprego de objeto que possa ser identificado como arma e não de um instrumento qualquer, mesmo que vulnerante, ocasionalmente para ameaçar ou ferir” (TACRIM - AC - Rel. Adalberto Spagnuolo - JUTACRIM - 71/378). Vale ressaltar que a distinção entre armas próprias e impróprias não é nova, o que equivale dizer que o legislador, se quisesse, poderia ter incluído no texto legal menção expressa a respeito. Como ensina o catedrático alemão Claus Roxin, para que se afirme que a norma legal comporta interpretação extensiva é necessário que se verifique se o legislador se desincumbiu do extrato de literalidade possível em seu tempo e espaço. Não o tendo feito, a ampliação de conceitos importa, na verdade, em analogia, que se prejudicial ao réu não poderá ser admitida. Que não se diga que houve “cochilo” ou equívoco seu, uma vez que é cediça que a utilização de armas próprias representa, no mais das vezes, um perigo muito maior a integridade física da vítima. **III - DA PENA BASE E DA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO PARÁGRAFO 4º DO ART. 33** A pena deve ser fixada no mínimo em face de todas as circunstâncias para o roubo e também para o tráfico. Requer-se, ainda aplicação de diminuição de pena em face da primariedade, dos bons antecedentes do acusado e das demais condições que estão presentes. Prevê o §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos que: “Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” A todos esses requisitos o acusado atende (primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem tampouco integra organização criminosa, não havendo, portanto, nada que o desabone). Cabe destacar que se tratando de réu primário e de bons antecedentes, que não ostenta envolvimento com nenhuma organização


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

criminosa, imperiosa a concessão do benefício, não se compreendendo sequer o que pretendeu dizer o legislador quando consignou que aquele que se dedica a atividades criminosas não faz jus a redução de pena. Ora, se o réu não se dedica a nenhuma outra atividade criminosa é ele inocente da imputação de tráfico. Em sentido oposto, se ela exercia o tráfico e é primário, de bons antecedentes, deverá ser condenado, mas fará jus a redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. É o que ressalta o festejado autor de Direito Penal e Processual Penal Guilherme de Souza Nucci: *“Na norma do §4º, para que se possa aplicar a diminuição da pena, afastou-se a possibilidade de ser reincidente ou ter maus antecedentes. Portanto, não se compreende o que significa a previsão de não se dedicar às atividades criminosas. Se o sujeito é reincidente ou tem maus antecedentes pode-se supor que se dedique a atividade criminosa. No mais, sendo primário e de bons antecedentes não há cabimento em se imaginar a dedicação a tal tipo de atividade ilícita.”* (Obra Supracitada, 2ª Ed., RT, 2007, p. 330). Salvo melhor juízo, nos parece que a única interpretação possível e razoável que pode ser dada a expressão “não se dedicar a atividades criminosas” é aquela que preconiza a aplicação do benefício quando o réu dedica-se a atividades criminosas diversas da que lhe são imputadas no processo por delito de tráfico. Definitivamente não é o caso, portanto, imperiosa a concessão ao réu a diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois em contexto como este a aplicação do desta causa de diminuição de pena é obrigatória, traduzindo-se em autêntico direito subjetivo do réu, conforme ressalta a doutrina: *“A redução decorre de antigo anseio dos juristas, a fim de corrigir distorções existentes nas leis anteriores revogadas. Antes da vigência da Lei m. 11.343/2006, qualquer pessoa condenada pela prática de tráfico ilícito de drogas, teria que cumprir, no mínimo, três anos de reclusão, em regime integralmente fechado, possibilitando-se, apenas, a concessão de livramento condicional após cumpridos dois terços da reprimenda. A redução, assim caracteriza significativo avanço legislativo, possibilitando ao julgador analisar, com amplitude, as condições subjetivas do agente, a fim de melhor obedecer ao princípio da individualização da pena. Trata-se de direito subjetivo do réu. Uma vez preenchidos os requisitos legais, a redução é obrigatória, ficando a cargo do juiz a estipulação do quantum a ser diminuído.”* (Leis Penais Especiais, Ed. Juarez de Oliveira, 2006, Vários autores, Coordenador Roberto Mendes de Freitas Jr.).

IV- DO REGIME ABERTO E DA APLICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS Prosseguindo sendo o réu indivíduo primário e de bons antecedentes, cabível a fixação do regime inicial aberto. Neste diapasão, presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, quais sejam: I (crime cometido sem violência ou grave ameaça), II (réu não reincidente em crime doloso) e III (circunstâncias judiciais favoráveis), não se pode afastar a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviço à comunidade. Também inafastável o direito do réu ter sua pena privativa de liberdade substituída por sanções restritivas de direitos. É que o óbice outrora existente na lei de droga foi suprimido pela resolução do Senado Federal, que cumprindo decisão do Supremo Tribunal Federal, afastou o óbice legal a substituição da pena privativa de liberdade por delito de tráfico por sanção restritiva de direitos. O afastamento da substituição da pena, mesmo em caso de tráficos praticados por indivíduos primários, com bons antecedentes e conduta social adequada, tem por consequência o povoamento de nossas prisões por pessoas sem passagem criminal anterior e sob as quais sequer pesa suspeita de envolvimento com facções criminosas. Por estes motivos, o Senado Federal, através da resolução nº 5 de 15 de fevereiro de 2012, suspendeu, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução de parte do § 4º


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Conforme artigo 1º o Senado Federal resolveu: “*É suspensa a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS*”. Neste diapasão, presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, quais sejam: I (crime cometido sem violência ou grave ameaça), II (réu não reincidente em crime doloso) e III (circunstâncias judiciais favoráveis), não se pode afastar a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviço à comunidade. Por fim, na sentença deve se observar o disposto no art. 387, §2º do CPP, inserindo-se o réu no regime prisional subsequente, caso se verifique o tempo de prisão provisória em regime equivalente a fechado é igual ou superior a um sexto da pena cominada ou caso a pena restante possa ser cumprida em regime menos gravoso, de acordo com o mais recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao não mais considerar o tráfico privilegiado como crime hediondo, Diante de todo o exposto, a Defensoria Pública requerer ao colhimento dos pedidos acima expostos.”

Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DELIBERAÇÃO / SENTENÇA:

VISTOS. O Ministério Público ingressou com a presente ação penal, imputando ao réu **EDIO BARBOSA PEREIRA**, devidamente qualificado, a prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I do Código Penal e artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, em razão da subtração, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de uma faca, de um aparelho celular, marca LG, pertencente à vítima Daniel Araujo, bem como em razão da posse, para fins de tráfico, de 47 porções de maconha, com peso total de 72g, de 04 pinos contendo cocaína, com peso total de 3,9g e de 37 pedras de crack com peso total de 6,3g, fatos estes ocorridos no dia 10 de janeiro de 2017, por volta das 17:00 horas, na Rua Aracati, 275, Penha, nesta Capital. Em sede de Departamento de Inquéritos Policiais, foi a prisão em flagrante convertida em preventiva. Não tendo sido vislumbradas hipóteses que levassem à rejeição liminar da denúncia, foi determinado, o processamento da ação penal (fls. 98/100). O réu foi pessoalmente citado (fls. 124). Apresentou resposta escrita (fls. 131/133). A denúncia foi formalmente recebida (fls. 138/140). Em início de instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Nesta data, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela defesa, e, ao final, foi o réu interrogado. Não tendo sido requeridas diligências, passou-se aos debates. O Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos exatos termos constantes na denuncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu batendo-se pela fragilidade das provas colhidas. Subsidiariamente, requereu a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviço à comunidade; a aplicação da pena no mínimo; o direito de recorrer em liberdade; a aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas. **Eis, em síntese, o relatório. Passo, em seguida, a fundamentar. 1. Das provas produzidas.** A persecução penal foi instaurada por força de auto de prisão em flagrante lavrado pela autoridade policial responsável pelo 10º Distrito Policial, após o réu ter sido detido em poder de um objeto roubado além de substâncias entorpecentes. Quando da primeira audiência, o policial Diego confirmou o depoimento prestado em sede policial. Ou seja, estava em patrulhamento quando a vítima apareceu informando que tinha sido roubado. Juntamente com a vítima, foi até o local dos fatos onde a vítima apontou um rapaz. Ao abordá-lo encontrou em poder do réu um aparelho celular, bem como a quantidade de drogas referidas pela denúncia. O policial Daniel, por sua vez, confirmou que estava em patrulhamento pela via pública quando foi procurado por um rapaz, alegando que tinha sido vítima de roubo de seu aparelho celular. Diante das


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

informações prestadas pela vítima, foram até o local onde encontraram o réu em companhia de um segundo rapaz. Antes da abordagem, percebeu que o réu trazia consigo uma sacola no interior da qual encontrou diversas substâncias entorpecentes. Segundo o policial, em poder do réu foi encontrado o aparelho celular da vítima que, ademais, reconheceu o acusado como o responsável pela subtração. Na presente audiência, a testemunha William disse que estava na frente da casa de sua avó quando o réu apareceu convidando o depoente para fazer uso de maconha. Foram até um bar nas proximidades onde consumiram maconha que estava em poder de William e que foi oferecida ao acusado. Em dado momento, apareceu um rapaz o qual ofereceu um aparelho celular ao acusado que o adquiriu mediante o pagamento de R\$ 70,00 (setenta reais). Depois de pagar pelo aparelho celular, o vendedor retornou pedindo que o réu lhe devolvesse o aparelho. Naquele momento, o réu disse que somente devolveria o aparelho caso lhe fosse restituído o valor em dinheiro pago pelo aparelho. Passado algum tempo, policiais militares apareceram e revistaram o depoente e o acusado. Estava em poder, tão somente, de um cigarro de maconha. Foram, então, levados até o distrito policial, onde o acusado permaneceu preso. A testemunha Marcos trabalhava juntamente com o réu em serviço de reciclagem. No dia dos fatos, pediu para que o acusado entregasse material para a avó do William, entregando a ele a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais). Após, não mais viu o réu. Quando do interrogatório, o réu negou envolvimento dos fatos. Foi até a casa de William e o convidou para consumir drogas. Em dado momento, uma pessoa apareceu oferecendo um aparelho celular, o qual foi adquirido pelo réu pela quantia de R\$ 70,00 (setenta reais). Depois de pagar, aquele mesmo rapaz retornou pedindo a devolução do aparelho. O réu disse que apenas devolveria caso o valor pago fosse restituído. Depois de algum tempo, os policiais apareceram e o abordaram. Estava em poder, tão somente, de um cigarro de maconha, negando, dessa forma, a posse de drogas indicada na denúncia. **2. Da valoração da prova.** A ação penal é parcialmente procedente. **2.1. Da responsabilidade do réu com relação ao crime de tráfico de drogas.** A materialidade foi demonstrada. Com efeito, o auto de exibição e apreensão aponta para o encontro de diversos invólucros contendo substâncias de colorações diferentes, além de uma quantia. As substâncias foram submetidas a exame preliminar de constatação o qual detectou sinais para cocaína em forma de pedra e em pó, além de maconha (fls. 24). Tal apreciação preliminar foi confirmada ao final pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 143/145). Os depoimentos prestados pelos policiais são uniformes e permanecem os mesmos desde os estágios iniciais da persecução. Ou seja, dirigiram-se até o local dos fatos após terem sido procurados pela suposta vítima que apontou o réu como o responsável pelo roubo de seu aparelho celular. Ao abordá-lo, encontraram, em seu poder, uma sacola plástica no interior da qual havia o entorpecente referido pela denúncia. Tais depoimentos, note-se, são consistentes, inexistindo contradições. Não há, por outro lado, razões para que tais relatos sejam desqualificados. Nesse cenário, não é possível desconsiderar aquela prova sob argumento de que emanaria, exclusivamente, de agentes policiais. Afinal, a legislação processual não se filiou ao modelo da prova tarifada segundo o qual os meios de prova registram valores apriorísticos os quais deveriam ser seguidos, fielmente, pela autoridade judiciária. Ao contrário, seguindo a tradição processual nacional, o modelo adotado é o do livre convencimento motivado. Logo, o julgador tem liberdade na avaliação e na ponderação dos diversos meios de prova que compõe todo o cenário cognitivo. No caso em apreço, como já exposto, não há razões para que os depoimentos prestados pelos policiais sejam desqualificados. Para além da manifesta coerência, não há registros de desinteligência anterior com a pessoa do réu que, de algum modo, sustentasse o argumento de que este teria sido vítima de uma armadilha. De


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

mais a mais, não há registro de desvios funcionais anteriores que comprometessem a idoneidade dos policiais. Nesse ponto, forçoso reconhecer a importância da prova por eles fornecida. Por outro lado, os depoimentos prestados pela testemunha William são manifestamente contraditórios. Em juízo, disse que o réu o teria convidado para consumir maconha e que estavam fazendo uso daquela substância quando os policiais apareceram. No entanto, em sede policial, nenhuma referência fez a tal aspecto. Limitou-se a dizer que estava em companhia do acusado quando os policiais apareceram. Aliás, sequer fez menção à transação do aparelho celular e que foi por ele referida sob o crivo do contraditório. Ademais, não há das substâncias apreendidas qualquer cigarro de maconha que William insiste em dizer que consumia quando da abordagem policial. Logo, as afirmações expostas por William não guardam coerência quando confrontadas entre si. Pior, não resistem aos relatos uniformes ofertados pelos policiais. Assim, a reconstrução histórica dos acontecimentos torna certa a imputação dada pela denúncia que atribui ao réu a posse das substâncias que foram apreendidas. A quantidade, a forma de acondicionamento e o local em que se deu a apreensão torna indubitoso o fato de que a posse das substâncias não se destinava ao uso pessoal, mas sim ao consumo de terceiros. Quanto ao valor em espécie encontrado, o relato fornecido pela testemunha Marcos levanta dúvidas razoáveis de que ao menos aquele valor fosse produto de venda de drogas. De qualquer modo, as dúvidas quanto à vinculação do numerário com o tráfico não desqualificam a ocorrência deste pelas razões detalhadamente expostas por este juízo; **2.2 Da improcedência da ação penal relativamente à imputação do roubo.** Melhor sorte não merece a acusação relativamente à atribuição do crime patrimonial. Segundo consta, os policiais se dirigiram até o local após a suposta vítima procura-los alegando que tinha sido vítima de uma subtração violenta praticada pelo réu. Esta narrativa, contudo, está circunscrita às alegações feitas pela vítima em sede policial e que não se repetiram em juízo já que a vítima não mais foi localizada. Os policiais, por sua vez, não presenciaram a ação delituosa mas apenas reproduziram o que a vítima teria a eles informado. No entanto, há alguns aspectos que suscitam dúvidas quanto à confiabilidade da narrativa prestada pela vítima. De fato, ela própria admitiu a condição de usuária de drogas. Mais do que isto, afirmou ter feito uso de drogas antes de procurar os policiais para relatar a ocorrência do roubo. Disse, inclusive, que teria aguardado o efeito da substância passar para então pedir auxílio aos policiais. Ora, diante de tal quadro se torna difícil reconhecer um estado de consciência perfeito que lhe permitisse identificar exatamente o que teria ocorrido. Não se descarta a possibilidade de que o celular tenha sido dado ao acusado como forma de pagamento das substâncias adquiridas e consumidas. A bem da verdade, há dúvidas razoáveis quanto à configuração do roubo tal como descrito e imputado pela denúncia de tal sorte que a solução mais adequada é a absolvição quanto a esta imputação. **3. Da individualização da pena.** O réu é primário e não registra antecedentes criminais. Não se pode olvidar, contudo, da natureza das substâncias apreendidas. Dentre elas encontrava-se cocaína em forma de pó e de pedra. Como se sabe, tais substâncias tem um alto poder lesivo à integridade física. Provoca, ademais, intensa e rápida dependência. A quantidade era expressiva. Nos termos do art. 42, da lei de drogas, fixo a pena base acima do limite mínimo, e com o acréscimo de 1/6. Obtém-se, dessa forma, a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583-dias-multa. Em que pese a primariedade do acusado, deixo de aplicar o redutor previsto no §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, tendo em vista que recentemente, decidiu-se que a causa de diminuição afastaria a equiparação do tráfico aos crimes de natureza hedionda. Esta nova percepção sobre o tráfico privilegiado traduz uma política criminal que busca reconhecer a menor reprovabilidade do tráfico de drogas de pequena proporção.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

Definitivamente não é a hipótese dos autos, dada a expressiva quantidade de drogas e também dada a natureza de algumas substancias. Trata-se, portanto, de criminalidade que exige maior reprovabilidade, adequada com o mandamento constitucional que equipara o tráfico aos crimes hediondos. Mantenho, dessa forma, a pena nos patamares inicialmente estabelecidos. No mais, tratando-se de imputação de comércio ilegal de drogas, a imposição de regime mais brando, mostra-se inadequada em razão da gravidade natural da conduta criminoso. Aliás, o tráfico de entorpecentes propicia o enriquecimento fácil às custas do consumo e, sobretudo, do vício de alguns. Registre-se, ademais, o tipo de entorpecente apreendido, o qual provoca intensa e rápida dependência. Assinalo, por fim, ser o réu reincidente. Por tais razões, e atento à finalidade retributiva e também preventiva da sanção penal, fixo o regime inicial fechado. Quanto ao valor do dia multa, ausentes informações sobre a condição financeira do réu, cada qual é estabelecido em seu menor valor monetário. Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, pois, a gravidade e a reprovabilidade do comportamento são incompatíveis com o regime jurídico mais brando das penas alternativas, tanto é verdade que se reconheceu no caso a necessidade de imposição de regime inicial fechado. **4. Decido.** Nos termos do exposto, julgo **parcialmente procedente** a presente ação penal, para: **4.1. Absolver, como de fato absolver,** o réu **EDIO BARBOSA PEREIRA**, portador de RG 37.412.265, filho de Zilta da Conceição Barbosa Pereira e Júlio Evangelista Pereira da imputação prevista no artigo 157, §2º, I do Código Penal, com **fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal;** **4.2. condenar, como de fato condeno,** o réu **EDIO BARBOSA PEREIRA**, portador de RG 37.412.265, filho de Zilta da Conceição Barbosa Pereira e Júlio Evangelista Pereira, **à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.** O réu está preso por força da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva. Não há nos autos elementos que indiquem o exercício de atividade lícita, ainda que em caráter informal, o que traz riscos à ordem pública. Não há, igualmente, notícias acerca de vínculo residencial, o que denota dúvidas acerca da efetiva aplicação da lei penal. Dessa forma, ***mantenho a sua custódia.*** Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Autorizo a incineração da substância entorpecente apreendida. Autorizo a destruição da faca apreendida. Ausentes elementos que indiquem o vínculo do numerário apreendido com o tráfico de entorpecentes, autorizo a sua devolução ao réu. Expeçam-se os ofícios necessários. Oficie-se para adequação da prisão do réu ao regime ora estabelecido. Extraia-se cópia dos depoimentos prestados, encaminhando-se ao Ministério Público para apuração de eventual prática de crime de falso testemunho. **P.R.I.C..**

O termo de audiência é assinado eletronicamente pelo MM Juiz, consoante o disposto no art. 1.269 das Normas da Corregedoria do TJSP, sendo via física entregue às partes ao final dos trabalhos. Os depoimentos prestados em audiência estão documentados em mídia audiovisual, que permanecerá arquivada em cartório. A qualificação das pessoas ouvidas neste ato está lançada em separado. As partes não alegaram nenhuma contradição no presente termo. Saem todos cientes do teor do presente termo. Eu, Ricardo Bastianon, Assistente Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Marcos Alexandre Coelho Zilli



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

15ª VARA CRIMINAL

**Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP
01133-020**

Promotor(a):

Celso Élio Vannuzini

Defensor(a):

Dra. Mônica de Melo

Réu

EDIO BARBOSA PEREIRA

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**